

제7장 당사자승계

제7장 당사자승계

I. 서설

강제집행에 있어서 집행권원이 성립된 후 집행개시까지 사이에 당사자의 변동이 있었던 경우에는 승계집행문의 부여를 받지 않으면,¹⁾ 승계인이 또는 승계인에 대하여 강제집행신청을 할 수 없다. 그러나 집행이 개시된 후에 당사자의 변동이 있었던 경우에는 민사집행법 및 민사집행규칙에서 특별한 규정을 두고 있다.

또한 담보권실행에 있어서는 집행개시 전후에 불구하고 원칙적으로 당사자에게 승계가 있었던 때에는 신청 또는 그 절차의 속행을 구하는 승계인이 집행기관에 대하여 승계의 사실을 증명할 필요가 있다.

이하에서는, 채권에 대한 강제집행 및 담보권실행절차에 있어서 당사자에게 변동이 있었던 경우의 조치 및 문제점에 대하여 검토해 보기로 한다(아울러 가압류채권자의 승계가 있는 경우도 함께 보기로 함).

II. 집행개시 전의 승계

1. 채권자측에 승계가 있는 경우

가. 일반채권자

집행권원에 표시된 채권자에 대하여 사망(자연인인 경우) 혹은 합병(법인의 경우)의 사실이 발생한 때(일반승계) 또는 집행권원에 표시된 채권에 대하여 채권양도 등의 사실이 발생한 때(특정승계)는 그 자를 위하여 승계집행문을 부여받아야 한다(민집 제31조).

확정된 지급명령(민집 제58조 제1항)과 가압류·가처분명령의 집행에 있어서는 집행문을 필요로 하지 않지만, 그 집행권원이 성립된 후에 당사자의 승계가 있어 승계인이 또는 승계인에 대하여 집행하려면 승계집행문을 받아야 한다(민집 제58조 제1항 단서 제2호, 제3호, 제292조 제1항, 제301조).

1) 별지서식 [7-1] 승계집행문 부여신청서 참조(제7장 말미 수록)

이때의 집행문 부여는 판결에 당사자로 표시된 자의 승계인에 대하여도 집행력이 미치는 사실을 공증함으로써(민집 제25조 참조), 집행권원을 보충하는 의미가 있으며 승계집행문에 의하여 승계한 집행채권자 또는 집행채무자가 새로이 특정된다.

또한 이 경우 승계는 집행권원이 판결인 경우에는 사실심의 구두변론종결 이후에 생긴 것에 한하고(민소 제218조 제1항 참조), 그 밖의 집행권원의 경우는 그 집행권원의 성립 이후에 생긴 것에 한한다. 승계의 사실은, 집행문부여기관에 명백한 경우를 제외하고 채권자가 문서에 의해 증명해야 한다(민집 제31조 제1항 단서).

또한 강제집행신청시에 승계집행문 및 증명서등본의 채무자에 대한 송달이 강제집행개시요건으로 되어 있으므로(민집 제39조 제2항, 제3항),²⁾ 그 송달을 증명하는 문서도 함께 제출할 필요가 있다.

이에 관하여 실무상 문제로 되는 경우를 살펴보면 다음과 같다.

1) 포괄승계에 있어서 승계를 증명하는 서면

당사자가 사망함으로 인해 상속인에 대하여 또는 당사자인 법인의 합병이 있는 때에 합병으로 신설되거나 존속하는 법인에 대하여 승계집행문을 신청하는 경우에는, 그 승계를 증명하는 서면으로서 통상 피상속인과 상속인의 가족관계증명서·제적등본 또는 법인등기사항증명서를 제출하고 있다.

그러나 승계를 증명하는 증명서가 위 서면에 한정되는 것은 아니고 재판장이 심증을 얻을 수 있을 정도의 다른 증명서를 제출하여도 무방하다.

다만 제출한 서면만으로 재판장이 심증을 얻을 수 없다면 집행문부여의 소(민집 제33조)를 제기하여 다른 방법으로 승계를 증명하여야 할 것이다.

2) 공동상속의 경우

가) 급부의 대상이 가분인 경우에는, 상속에 의해 상속분에 응한 분할채권관계로 된다.³⁾ 따라서 채권자가 사망하고, 그 상속인이 공동상속인인 때는 각 상속인은 자기 상속분에 대하여 승계집행문의 부여를 받는 것이 가능하다. 집행문에는 집행가능한 범위로서 상속의 비율 또는 상속된 확정금액이 표시되므로 그 한도에서 청구하는 것이 가능하다.

나) 급부가 불가분채권이고, 승소판결을 받은 채권자가 사망하여 2인 이상의 상

2) 별지서식 [7-2] 승계집행문 및 승계사실증명서등본 송달신청서 참조(제7장 말미 수록)

3) 대법원 1962. 5. 3. 선고 4294민상1105 판결; 대법원 1980. 11. 25. 선고 80다카1847 판결(판례가족법 추록 I, 192.); 日最判 昭和 29(1954). 4. 8.(民集 8-4, 819); 박윤직, 상속법, 232.; 양창수, “공동상속재산의 공유”, 법정고시(1996. 9.), 34.

속인 공동으로 상속한 경우, 상속인 중 1인이 공동상속인 전원을 위하여 승계집행문의 부여를 받을 수 있는가에 대하여는 논의가 있다.

이를 소극적으로 해석하는 견해는 이 경우 상속인 중 1인이 자기를 위하여 전부 급부에 관한 승계집행문의 부여를 구할 수는 있지만 공동상속인 전원을 위하여 승계집행문의 부여를 구할 수는 없다는 것이나, 이 경우 그 취지를 승계집행문에 기재하고 나머지 공동상속인과 함께 전원을 위하여 승계집행문을 부여할 수 있고 공동상속인 중 1명이라도 제외하고서는 승계집행문을 부여할 수 없다는 적극설이 타당할 것이다.^{4) 5)}

다) 또한 집행문에 상속인이 2명뿐인 것으로 부여되었는데, 집행관(또는 집행원)이 그 밖에 상속인이 더 있다는 것을 알았다고 하더라도 집행문에 따라 집행하여야 한다.

3) 숙려기간 중의 부여

자연인이 사망한 경우에는 상속인은 상속의 개시를 안 때로부터 3월 내의 숙려기간 중에 한정승인 또는 상속포기⁶⁾를 할 수 있고, 상속채무가 상속재산을 초과하는 사실을 중대한 과실 없이 위 기간 내에 알지 못하고 단순승인을 한 경우에는 그 사실을 안 날로부터 3월 내에 한정승인을 할 수 있다(민법 제1019조 제1항, 제3항).

상속인이 위와 같은 숙려기간 중에 승계집행문을 부여하는 것이 가능한가 여부가 문제로 될 수 있지만, 채무자는 숙려기간 내에 상속포기가 있었던 것을 이유로 하여 승계집행문 부여에 대한 이의의 신청(민집 제34조) 또는 이의의 소(민집 제33조)에 의해서 부여된 집행문에 의한 강제집행의 배제를 구하는 것이 가능하므로 숙려기간 중에 승계집행문을 부여할 수 있다고 보는 것이 실무의 대세이다.⁷⁾

4) 채권양도 등의 경우

채권양도를 받은 채권자가 승계집행문을 부여받기 위해서는, 양도를 증명하는 문서를 제출해야 한다. 이 경우 양도증서 등과 같은 양도계약 자체를 증명하는 문서 외에 제3자에 대한 대항요건으로서의 채무자에 대한 양도통지서 또는 채무자의 승낙사

4) 법원실무제요 민사집행(I), 법원행정처(2014), 211.

5) 다만 적극설에 의하더라도 공유물의 보존행위로서 공유자 중의 1인이 그 명도청구를 하는 경우에는 나머지 공동상속인과 함께 전원을 위해 승계집행문을 부여받지 않고 자신만을 위한 승계집행문을 부여받을 수 있을 것이다.

6) 상속포기는 일단 상속한 후에 상속인으로서의 지위를 상속개시시에 소급하여 소멸시키는 것이다.

7) 위 법원실무제요 민사집행(I), 211.

실까지 증명을 요하는가가 문제로 되지만, 실무는 이러한 사실도 채권자에게 입증책임이 있는 사실이기 때문에 그 증명이 필요하다고 해석한다.⁸⁾

또한 판결에 표시된 채권을 압류한 제3자가 그 채권을 전부받았음을 이유로 승계집행문의 부여를 신청할 때에는 그 전부명령의 정본 또는 등본과 그 확정증명을 제출하여야 한다.

5) 대위변제의 경우

가) 제3자가 채무자를 대신하여 채무를 변제한 경우 그 변제에 대하여 정당한 이익을 가지는 때는 변제에 의해 당연대위한다(민법 제481조, 이른바 법정대위). 여기서 정당한 이익을 가지는 자란, 연대채무자, 보증인, 연대보증인 등을 말한다.

그리고 정당한 이익을 가지지 않는 때에는 채권자의 승낙을 얻어 또 채무자에게 그 취지의 통지(또는 승낙)하는 것에 의해 채권자에게 대위한다(민법 제480조 제1항, 제2항). 위와 같이 집행권원에 표시된 채무자를 위하여 대위변제한 자는 채권자로부터 그 집행권원을 교부받았는지 여부와 관계없이 승계집행문을 받아 채무자에게 집행할 수 있다.

법정대위의 경우의 정당한 이익을 가짐을 증명하는 문서로서는, 변제자가 연대채무자등으로서 계약한 것을 증명하는 계약서, 변제영수증 등이 있다. 그리고 임의대위의 경우에는 채권자의 승낙서, 채권자로부터 채무자에 대한 통지서 및 배달증명서 또는 채무자의 대위승낙서(민법 제480조 제2항 참조), 변제영수증 등이 있다. 대위변제자가 채권자로부터 집행력 있는 정보를 교부받았을 때에는 그 집행정보도 집행문부여기관에 제출하여야 한다.

나) 연대채무자 또는 보증인이 주채무자와 공동피고가 되어 패소판결을 받은 후 채권자에게 변제하고 다른 연대채무자 또는 주채무자에게 구상권을 행사할 경우에도 민법이 정하는 범위 내에서 채권자를 대위하여 권리를 행사할 수 있으므로(민법 제425조 제1항, 제441조 제1항, 제444조 제1항, 제447조, 제448조, 제481조), 이때에도 승계집행문을 부여받는 것이 가능하다.

이와 같은 구상권을 행사하기 위하여 대위하는 자는 승계집행문부여신청시 승계의 증명서로서 채권자로부터 교부받은 집행력 있는 정보(전부 변제의 경우) 또는 영수증을 제출하여야 한다. 이 경우 승계집행문을 부여받을 수 있는 것은 피구상자가 판결에 공동당사자로서 표시된 경우에 한한다. 또한 그 판결에서 구상자와 피구상자

8) 위 법원실무제요 민사집행(I), 212. 참조

의 부담부분을 확정하고 있어야 하며,⁹⁾ 승계집행문에는 피구상자에 대하여 집행할 수 있는 부담부분을 명백히 표시하여야 한다.

나. 담보권리자의 경우

절차개시 전에 담보권자에 대하여 승계가 있었던 경우에는, 피승계인에 대한 절차개시문서(민집 제264조) 외에 승계를 증명하는 문서를 함께 제출함으로써 집행의 신청을 할 수 있다.

이 경우 승계를 증명하는 문서로서는, ① 일반승계에 있어서는 공문서(가족관계 증명서, 상업등기사항증명서 등) 또는 사문서(유류분 분할협의서등), ② 특정승계에 있어서는 피담보채권의 양도계약서, 채무자의 채권양도통지서 및 배달증명서, 채무자의 승낙서 등이 이에 해당한다.

다만 권리의 이전에 대하여 등기 및 등록을 요하는 그 밖의 재산권을 목적으로 하는 담보권에 대하여 승계가 있었던 후에 신청을 한 때는, ① 일반승계에 있어서는 그 승계를 증명하는 문서(공문서, 사문서를 불문하고), ② 특정승계에 있어서는 그 승계를 증명하는 공문서를 제출해야 한다.

2. 채무자측에 승계가 있는 경우

채권에 대한 강제집행에서 집행권원에 표시된 채무자에게 승계가 있으면, 그 자에 대해 집행하기 위해서는 승계집행문의 부여를 받을 것을 요한다(민집 제31조).

채권에 대한 담보권실행의 채무자에게 승계가 생긴 경우에도 승계를 증명해야

9) 대법원 1991. 10. 22. 선고 90다20244 판결【판결요지】[1] 수인의 불법행위로 인한 손해배상책임은 부진정연대채무이나 그 구상권행사에 있어서는 성질상 연대채무에 관한 규정이 준용된다고 할 것인데 그 구상권에 관하여 규정한 민법 제425조 제1항의 규정에 의한 구상권 행사의 상대방은 공동면책이 된 다른 연대채무자에 한하는 것이며 다른 연대채무자가 그 채권자에게 부담하는 채무를 연대보증 한 연대보증인은 그 연대채무자와 연대하여 채권자에게 채무를 변제할 책임을 지는데 불과하고 채무를 변제한 연대채무자에게까지 그 연대보증한 연대채무자의 부담부분에 관한 채무를 변제할 책임을 부담하는 것은 아니라고 할 것이다. [2] 변제자대위에 의하여 변제자에게 이전되는 채권에 관하여 채권자가 이미 확정판결에 의한 채무명의를 받아 가지고 있는 경우라 할지라도 채권자로부터 변제자에게로 이전되는 권리가 1인의 채무자에 대한 권리 등의 경우처럼 채무자의 부담부분을 따질 필요가 없거나 달리 부담부분별로 분할하여 소구할 필요가 없는 경우에는 바로 승계집행문을 부여받아 그 권리를 행사할 수가 있으므로 별도로 구상금청구 소송을 제기할 소의 이익이 없다고 할 수 있겠으나, 구상권을 행사할 수 있는 각 채무자의 부담 부분이 따로 있고 그 확정판결에서 각 채무자의 부담부분을 확정하고 있지 않은 경우에는 확정판결에 의한 승계집행문을 부여받는다 하여도 그가 구상하고자 하는 부분에 대한 집행을 할 수는 없는 것이므로 실제로 구상할 수 있는 부담부분 등 그 구상 범위를 확정하기 위하여 별도의 구상금청구 소송을 제기할 소의 이익이 있다.

하지만, 특히 이에 관한 규정이 없기 때문에, 승계를 증명할 문서에는 제약이 없는 것으로 해석되고 있다.

채권에 대한 강제집행에 있어서 문제로 되는 경우에 대하여 살펴보면 다음과 같다.

가. 공동상속의 경우

급부의 대상이 가분인 경우에는 - 채권자부분에서 서술한 것과 동일하게 - 상속에 의해 상속분에 응한 분할채무관계로 되므로,¹⁰⁾ 채무자가 사망하고 그 상속인이 공동상속한 때는 각 상속인의 상속분에 대하여 승계집행문의 부여를 받을 수 있다. 채권자는 각 상속인에 대하여 집행문에 기재된 한도 내에서 청구할 수 있다.

공동상속인들의 건물철거의무는 그 성질상 불가분채무에 속하는 바,¹¹⁾ 이러한 내용을 가진 판결의 집행을 위해서는 상속인 전원에 대한 승계집행문이 필요하다고 볼 것이다.

나. 한정승인의 경우

채무자에 대하여 상속이 개시되고 그 상속인이 한정승인한 때는 그 상속인은 상속재산의 한도에서 변제의 책임을 부담하게 된다. 한정승인한 사실은, 채무자가 증명해야 하는 사실이지만, 채권자로서는 집행문부여의 신청시에 가정법원의 접수증명서도 함께 제출하는 것이 상당할 것이다.

다. 채무인수의 경우

채무명의에 표시된 채무자의 특정승계인에 대하여도 승계집행문을 부여받을 수 있다. 이 경우 승계를 증명하는 문서로서는 3자(채권자, 채무자, 인수인) 사이의 계약

10) 양창수(주3), 37.; 대법원 1997. 6. 24. 선고 97다8809 판결【판결요지】[1] 금전채무와 같이 급부의 내용이 가분인 채무가 공동상속된 경우, 이는 상속 개시와 동시에 당연히 법정상속분에 따라 공동상속인에게 분할되어 귀속되는 것이므로 상속재산 분할의 대상이 될 여지가 없다. [2] 상속재산 분할의 대상이 될 수 없는 상속채무에 관하여 공동상속인들 사이에 분할의 협의가 있는 경우라면 이러한 협의는 민법 제1013조에서 말하는 상속재산의 협의분할에 해당하는 것은 아니지만, 위 분할의 협의에 따라 공동상속인 중의 1인이 법정상속분을 초과하여 채무를 부담하기로 하는 약정은 면책적 채무인수의 실질을 가진다고 할 것이어서, 채권자에 대한 관계에서 위 약정에 의하여 다른 공동상속인이 법정상속분에 따른 채무의 일부 또는 전부를 면하기 위하여는 민법 제454조의 규정에 따른 채권자의 승낙을 필요로 하고, 여기에 상속재산 분할의 소급효를 규정하고 있는 민법 제1015조가 적용될 여지는 전혀 없다.

11) 대법원 1980. 6. 24. 선고 80다756 판결【판결요지】공동상속인들의 건물철거의무는 그 성질상 불가분채무라고 할 것이고 각자 그 지분의 한도 내에서 건물 전체에 대한 철거의무를 지는 것이다.

서를 생각해 볼 수 있다.¹²⁾

그리고 중첩적채무인수의 경우에 인수인에 대한 승계집행문의 부여가 가능한가에 대하여는, 가능하지 않다는 견해¹³⁾와 가능하다는 견해¹⁴⁾가 대립하고 있다.

3. 제3채무자의 승계

채권에 대한 강제집행 또는 담보권실행의 신청 전에 제3채무자에게 일반승계가 생긴 때는 채무자가 제3채무자의 일반승계인에 대하여 가지는 채권을 압류하게 된다.

이 경우 채권집행은, 압류채권의 존부를 조사하지 않고, 일응 그것이 존재하는 것으로 보아 발령하는 것이기 때문에, 채권자는 집행신청시에 그 일반승계 사실을 증명하는 문서를 제출할 필요는 없다고 볼 것이다.¹⁵⁾

Ⅲ. 집행개시 후의 승계

1. 채권자측에 승계가 있는 경우

가. 일반채권자의 경우

1) 강제집행을 개시한 후 집행신청채권자에 대하여 일반승계 또는 특정승계가 생긴 때는 그 승계인은 승계집행문이 부여된 집행권원의 정보를 집행기관에게 제출하여 계속중인 절차의 속행을 구할 수 있다(민집규 제23조 제1항). 이와 같은 경우에도 법원사무관등은 채무자에 대하여 승계집행문이 부여된 집행권원의 정보가 제출된 취지를 통지해야 한다(민집규 제23조 제2항).

따라서 집행개시 전의 승계와 달리 승계집행문 및 증명문서의 각 등본이 채무자에게 송달되어 있을 필요는 없다.

2) 또한 이 경우 집행권원의 정보는 이미 집행법원에 제출되어 있기 때문에, 승계집행문의 부여를 받는 방법이 문제로 되지만, 승계집행문의 부여를 받는 데에 필요하다는 소명이 있으면, 집행법원의 법원사무관등은 집행법원에 제출되어 있는 집행력 있는 집행권원의 정보를 일시 승계인에게 반환할 수 있고, 승계인은 이것을 집행문부

12) 위 법원실무제요 민사집행(I), 212.

13) 深澤利一, 民事執行の實務(下), 新日本法規(1997), 425.

14) 吉野 衛·三宅弘人 共著, 香川保一 監修, 注釋民事執行法(2), きんざい, 平成 7年(1995), 186.

15) 東京地裁債權執行等手續研究會, 債權執行の諸問題, 判例クイムズ사, 21.

여기관에 제출하여 승계집행문의 부여를 받을 수 있다고 해석된다.¹⁶⁾

3) 그런데 신청채권자에 대하여 일반승계의 사실이 있었던 것이 집행기관에 명백함에도 불구하고(민집 제31조 제1항 단서 참조), 승계의 절차가 취해지지 않은 경우의 취급에 대하여는 다음과 같이 견해의 대립이 있다.

즉 제1설¹⁷⁾은 이 경우 민사집행법 제23조에 의해 민소법 제233조, 제234조가 준용되어 집행절차가 중단된다고 보며, 제2설¹⁸⁾은 이 경우 승계절차가 취해지지 않는 한 전주(前主)를 위해 절차가 속행되지만 채권자의 관여를 요하는 때에는 사실상 정지하는 것으로 주장한다. 다음으로, 제3설¹⁹⁾은 이 경우 집행절차를 사실상 정지하고 승계인에게 승계절차를 촉구하여 이것에 응하지 않은 때는 집행을 취소한다는 것이다.

생각건대 집행절차에 있어서 당사자의 교체는 집행기관이 형식적으로 판단해야 하고, 집행정보에 표시되어야 하는 것으로 해석되며, 또 집행절차가 직권진행주의적인 것이므로 중단의 규정을 준용하는 위 제1설에는 의문이 있다. 또한 집행절차상 당사자능력을 상실한 때는 그 후의 집행기관의 집행처분은 무효라고 해석되므로 그 점을 고려하지 않는 위 제2설에도 의문이 있다. 따라서 위 견해 중에서 제3설이 타당하다고 여겨지지만, 실무상으로는 제2설에 따라 처리할 수도 있다고 본다.

4) 그런데 신청채권자가 집행권원상의 채권을 양도하는 등 특정승계가 생긴 경우에 있어서는 그 사실이 집행기관에 판명되었어도 승계인이 승계집행문을 제출하여 속행을 구하지 않는 한 피승계인을 위해 절차를 속행하는 수밖에 없다(민집 제31조 제1항 참조).

또한 이 경우 채무자로서는 청구이의의 소를 제기하고 피승계인을 위한 집행절차를 배제할 수 있다.²⁰⁾

나. 담보권리자의 경우

절차개시 후에 담보권자에게 승계가 있었던 경우, 승계인이 신당사자로서 절차의 속행을 구하려면 집행기관에 대해 승계의 사실을 증명해야 한다(민집규 제202조, 제23조).

16) 東京地裁債權執行等手續研究會(주15), 21.

17) 田中康久, 新民事執行法の解説(増補改訂版), 金融財政事情研究會, 111.

18) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(2), 638.

19) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(1), 715.

20) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(2), 636.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(1), 715.

이 경우 일반채권자의 경우와 달리, 증명문서에 대한 제약은 없다. 다만 권리 이전에 대하여 등기 등을 요하는 그 밖의 재산권을 목적으로 하는 담보권실행의 경우, 일반승계가 있는 때에는 단순히 그 승계를 증명하는 문서로 족하지만, 그 밖의 승계가 있는 때에는 그 승계를 증명하는 재판등본 그 밖의 공문서를 제출해야 한다.²¹⁾ 예컨대, 저당권에 기초한 물상대위의 경우 저당권의 이전이 있었던 것을 저당권의 이전의 부기등기가 된 등기사항증명서에 의하여 증명할 필요가 있다.

또한 위의 강제집행부분에서 서술한 것과 동일하게, 절차개시 후에 담보권자에 대하여 승계가 있고 그 사실이 집행기관에 명백하게 되었지만 승계인으로부터 승계를 증명하는 문서가 제출되지 않은 때의 처리에 대하여는 그와 동일하게 다툼이 있다.²²⁾

2. 채무자측에 승계가 있는 경우

가. 일반채권의 경우

1) 채권에 대한 강제집행에서는 그 개시 후에 채무자가 사망한 경우에 있어서도 집행하는 것이 가능하다(민집 제52조 제1항). 상속재산이 강제집행의 대상으로 되는 한은, 승계의 유무에 대하여 심사할 필요가 없기 때문이다.²³⁾

따라서 채권압류명령의 효력이 생긴 후에 채무자가 사망하였어도 채권자는 승계 집행문의 부여를 받음이 없이 그 후의 절차를 속행하는 것이 가능하기 때문에 채권압류명령이 확정되면 제3채무자에 대하여 채권의 추심을 할 수 있다. 이것은 상속인의 존부나 상속의 승인 또는 포기 등에 의해 영향받지 않는다.

또한 앞서 본 속리기간 중이었어도 그 속행이 방해되지 않는다. 다만 채무자가 해야 하는 것 또는 채무자에 대하여 해야 하는 것은 생략할 수 없다고 해석되기 때문에, 채권압류명령정본의 송달 등 그 후의 절차는 상속인, 유언집행자, 상속재산관리인 또는 특별대리인(민집 제52조 제2항)에 대하여 할 것을 요한다.

2) 그러나 위와 같이 집행시에 승계집행문의 제출이 필요하지 않다고는 해도, 예컨대 추심 또는 전부명령을 신청하는 경우, 혹은 집행법원의 배당등 절차에서 만족을 받아 법원사무관등이 집행청구권의 소멸을 집행권원상 명확하게 하기 위해서 집행권원의 정보 말미에 이를 기재할 필요가 있는 경우 등에는 집행법원에 승계집행문이 부

21) 東京地裁債權執行等手續研究會(주15), 22.

22) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(5), 344.

23) 田中康久(주17), 110.

여된 집행권원의 정본을 제출할 필요가 있을 수 있다.

3) 그리고 채무자 회사 그 밖의 단체 등이 합병에 의해 소멸한 때에도 채무자의 사망에 준하여 합병 등 당시의 재산에 대하여 강제집행을 속행할 수 있다고 해석된다.²⁴⁾ 나아가 강제집행개시 후(압류 후)에 채무자의 채권양도 등으로 특정승계가 있었어도 그 처분은 압류명령의 처분제한효에 반하여 효력이 생기지 않기 때문에 강제집행의 속행을 방해하지 않는다.

나. 담보권의 경우

채권을 목적으로 하는 담보권실행에 있어서도 채권에 대한 강제집행과 동일하게 채무자가 사망하였다 하더라도 절차는 당연히 속행된다(민집 제275조, 제52조 제1항).

다. 제3채무자 승계의 경우

채권압류명령이 제3채무자에게 송달되면 압류의 효력이 생기고(민집 제227조 제4항), 제3채무자는 채무자에의 변제가 금지되기 때문에(민집 제227조 제1항), 그 후에 제3채무자에게 일반승계의 사실이 생겼어도 그 승계인은 피승계인과 동일하게 채무자에 대한 변제가 금지된다고 해석되므로 채권자에게 추심권이 발생한 때에는 채권자는 위와 같은 제3채무자의 승계인에 대해서도 추심권의 행사가 가능하게 된다.

IV. 가압류채권자의 승계

1. 서

민사집행법 제292조 제1항은, “가압류에 대한 재판이 있는 뒤에 채권자나 채무자의 승계가 이루어진 경우에 가압류의 재판을 집행하려면 집행문을 덧붙여야 한다.”라고 규정하고 있는바, 이 규정의 취지에 의하면, 일반 강제집행의 경우와 달리 보전명령에 있어서는 원칙적으로 집행문의 부여가 필요하지 않음을 알 수 있다.²⁵⁾ 이것은 보전명령이 그 성질상 즉시로 집행력이 생기고, 또 신속하게 집행될 필요성이 있는 점, 환가(현금화)·배당등이 없는 잠정적인 것인 점 등의 이유에 기초한 것이다.

24) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(2), 624.

25) 위 법원실무제요 민사집행(IV), 22.

당사자에 대하여 승계가 있었던 경우에는 승계집행문을 요하지만(민집 제292조 제1항), 이에 대하여는 보전명령 특유의 문제가 있다. 또한 보전명령의 집행에 있어서는 일반의 강제집행과 달리 집행기간의 정함이 있으며(민집 제292조 제2항), 이것에 관하여도 여러 문제가 있다. 채무자에 대한 재판정보 송달 전에 집행을 개시할 수 있는 점(민집 제292조 제3항)도 보전명령 집행의 특칙이다.

2. 승계집행문을 필요로 하는 경우

가압류집행에 있어서 예외로 집행문의 부여가 필요한 경우는, “채권자나 채무자의 승계가 이루어진 경우”이다(민집 제292조 제1항). 즉 채권자 또는 채무자에게 승계가 생긴 경우에는 가압류에 표시된 당사자와 집행의 당사자가 다르기 때문에, 승계집행문이 부여된 가압류정본에 기초하여 집행하게 되는 것이다. 여기에서 말하는 승계란 일반승계와 특정승계를 불문한다.

이와 관련하여, 가압류명령이 발하여진 후 채권자의 승계인이 보전소송상 채권자의 지위를 승계한 경우에 보전소송에 대한 이의 또는 취소소송에서 그 권리를 주장함에 있어서 승계집행문의 부여를 받아야 하는지 여부가 문제로 되고 있다. 이에 대하여는 이를 긍정적으로 해석하는 견해도 있어 보이나, 민사집행법 제292조 제1항은 보전명령의 집행상의 효력을 규정한 것에 불과하고 이것이 집행권원인 보전명령의 실체법상의 효력을 다투는 이의소송 또는 취소소송에 관한 것은 아니라 할 것이므로 이 경우 승계인이 피승계인의 보전처분상의 효과를 주장하려면 자기가 승계인임을 입증하면 충분할 뿐이고 여기에 승계집행문의 부여를 요하는 것은 아니라는 부정설이 타당하다고 본다.²⁶⁾

3. 승계의 기준시

가. 승계의 유무의 기준시는 가압류가 발하여진 때라고 해석된다. 따라서 가압류 발령 후 집행착수 전에 채권자 또는 채무자에게 승계가 생긴 경우에는 승계집행문이 필요하게 된다.²⁷⁾

나. 가압류명령의 신청 후 그 발령 전에 승계가 있었던 경우에는, 승계인이 기존의 보전명령절차를 승계해야 한다.

26) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅳ), 24-25.

27) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(7), 367.

가압류명령 신청의 심리 중에 있어서 당사자 지위의 승계에는 일반승계와 특정승계가 있다. 특정승계에 의한 경우에는 당사자가 스스로 나아가 승계하는 참가승계(민소 제81조) 혹은 상대방에 의한 신청에 의해 참가하는 인수승계(민소 제82조)의 절차에 의해 당사자의 변경절차가 취해진다.²⁸⁾ 참가승계의 경우 참가 신청인은 민소법 제79조에 의해 채권자와 채무자의 양자를 상대방으로 하는 독립 당사자참가를 하여, 채권자에 대하여는 보전명령신청의 각하를 구하고, 채무자에 대하여는 자기를 채권자로 하는 보전명령을 구하는 형식으로 하게 된다. 그리고 종전의 채권자는 민소법 제80조에 의한 탈퇴를 하고 승계절차가 종료되지만, 종전의 채권자가 탈퇴하지 않은 때에는 그 자는 당사자의 지위를 상실하지 않은 채 삼면관계(三面關係)의 절차가 계속된다.²⁹⁾

여기서 말하는 당사자 지위의 승계 또는 변동은, 당사자적격의 승계를 의미한다. 일반적으로, 당사자 적격의 승계는 소송물의 승계를 의미하지만, 보전명령신청절차에 있어서 지위의 승계가 있다고 말할 수 있기 위해서는 피보전권리와 함께 보전의 필요성에 대한 승계도 요하는가, 이것을 요한다고 해도 보전의 필요성의 승계란 무엇을 의미하는가에 대하여 논의가 있다.³⁰⁾ 또한 보전명령절차에 있어서도 독립당사자참가(민소 제79조)나 공동소송참가(민소 제83조), 보조참가(민소 제71조)를 할 수 있음은 말할 것도 없다(민집 제23조 제1항).³¹⁾

만일, 위와 같이 가압류명령 후 발령 전에 승계가 있었음에도 불구하고 보전명령절차를 중단하지 않았기 때문에 종전의 채권자를 위하여 또는 채무자에 대하여 가압류가 발령된 때에는 그 명령에 대하여 집행문을 내어줄 것인가가 문제로 된다.

그러나 이 경우에도 보전소송의 당사자가 일치하고 있지 않은 점은 가압류명령 후에 승계가 있는 경우와 다를 바 없으며, 보전소송의 신속성이나 소송경제적인 면에 비추어 보아도 민사집행법 제292조 제1항을 유추함으로써 집행문을 받아 집행할 수

28) 실무상으로는, 이러한 절차를 취하기보다는 일단 신청을 취한 후 새로운 당사자에 의한 재신청을 하는 편이지만, 위와 같은 절차를 취하는 것이 신속한 보전명령을 얻기 위해서 유효한 경우가 많다.

29) 柳川眞佐夫, 保全訴訟(補訂版), 判例タイムズ社(昭和 51), 209.

30) 보전의 필요성은 당사자간의 분쟁의 실태에 의해 정해지는 것이어서 원칙적으로 이전에 친한 것이 아니고, 또 승계인을 위하여 보전명령이 발하여지기 위해서는 승계인에 대하여 보전의 필요성이 있음이 인정되어야 할 것이다. 따라서 보전의 필요성의 승계를 필요로 하는 견해도 전당사자의 보전의 필요성이 그대로 이전하는 것을 의미하지는 않는다고 생각한다.

31) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅳ), 21-22.

있다고 봄이 타당할 것이다.³²⁾

다. 가압류집행착수 후 그 종료 전에 승계가 있었던 경우에는 채권자측과 채무자측에서 그 절차가 다르다.

먼저, 채권자의 승계가 있었던 경우에는 승계인은 특정승계, 일반승계를 불문하고, 승계집행문의 부여를 받아야 한다(민집규 제23조 제1항 참조). 이에 반해, 채무자에 대하여 특정승계가 있었던 경우에는 승계집행문의 부여가 필요하지만, 채무자가 사망한 경우에는 채권자는 승계집행문의 부여를 받지 않고 보전집행을 속행할 수 있다(민집 제291조, 제52조 제1항). 법인인 채무자가 합병한 경우에도 동일하게 승계집행문의 부여를 요하지 않는다고 해석되고 있다.³³⁾

라. 보전집행종료 후에 채권자를 승계한 자가 본집행절차에 있어서 보전집행의 효력을 주장하는 경우 승계집행문의 부여를 필요로 하는가 아닌가에 대하여는 다툼이 있다. 이는 예컨대, 가압류의 집행이 종료한 후에 피보전채권을 양수한 자가 당해 채권의 청구소송에서 본안판결을 얻어 강제집행을 하는 경우 당해 가압류명령에 승계집행문의 부여를 받지 않으면 가압류가 있는 본집행의 효력을 주장할 수 없는가라는 문제이다.

이에 대하여 이 경우도 승계집행문이 필요하다는 견해가 없는 것은 아니지만, 보전집행에 대한 승계집행문은 승계인이 그 보전집행절차에 관여하기 위한 것이므로 이미 위 절차가 종료하고 승계인의 위 절차에 대한 관여의 기회가 소멸하고 있는 때에는 집행문부여의 필요성도 소멸하기 때문에, 위와 같은 경우에는 승계집행문의 부여를 받지 않아도 본집행절차에 있어서 보전집행의 효력을 주장할 수 있다고 해야 할 것이다.³⁴⁾

다만 일단 보전집행이 종료한 후에 승계한 자라도 새로이 목적물에 대하여 현금화명령을 구하거나 또는 집行的 취소를 구하는 등 스스로 보전집행절차에 관여할 필요가 있는 경우에는 승계집행문의 부여를 받아야 한다.³⁵⁾

4. 집행문 부여의 절차

가. 법원사무관등의 부여

승계집행문은 승계의 사실이 법원에 명백한 때 또는 채권자가 문서를 가지고 중

32) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅳ), 23.

33) 兼子一, 増補強制執行法, 酒井書店(1979), 45.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(2), 624.

34) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅳ), 24.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(6), 347.

35) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅳ), 23-24.; 보전소송, 사법연수원(2013), 18.

명한 경우에 한하여 사건기록이 존재하는 법원의 법원사무관등이 부여한다(민집 제291조, 민집 제28조 제2항, 제31조 제1항).³⁶⁾

승계집행문의 부여에 대하여는 집행문부여등에 관한 이의신청(민집 제34조), 집행문부여의 소(민집 제33조), 집행문부여에 대한 이의의 소(민집 제45조)등의 각 규정이 준용된다(민집 제291조).

나. 보전의 필요성에 대한 심사

가압류명령에 승계집행문을 부여함에 있어서 승계인에 대하여 다시 보전의 필요성 유무를 심사해야 하는가에 대하여도 논의가 있다.

그 가운데 다시 심사해야 한다는 견해³⁷⁾는 보전사건의 소송물은 피보전권리의 존재와 보전의 필요성의 두 요건을 가지고 구성되어 있고 피보전권리에 관한 승계만에 의해 바로 승계집행문을 부여하는 것은 보전의 필요성이 없는 경우에도 집행이 가능한 것으로 되어 부당하다는 것이다.

이에 반해, 그 심사가 필요하지 않다는 견해³⁸⁾는 민사집행법에 있어서는 집행문의 부여는 법원사무관등의 권한으로 되어 있고, 그 절차는 형식적 요건에 대한 간이한 심사인 것을 전제로 하고 있는데, 이 경우 승계집행문의 부여에 있어서 보전의 필요성 유무를 심사해야 한다고 하는 것은 이와 같은 절차면에서 보더라도 의문이므로 위와 같은 심사는 불요하다고 주장한다.

위 문제는 승계집행문이 승계인과의 관계에서도 보전의 필요가 있는 경우에만 부여된다고 볼 것인가라는 점과 관련되어 있는 것이고, 이에 대하여 우리 실무는 원칙적으로 이를 긍정하고 있다.³⁹⁾ 즉 이 경우 승계집행문은 승계인과의 관계에서도 보전의 필요가 있는 경우에 한하여 그 부여가 허용된다는 것이다. 다만 나아가 이와 같은 승계의 경우 보전의 필요성이 갖추어 있는지 여부에 관하여는 일률적으로 판단할 성질이 아니고 보전소송의 특질과 구체적 사정에 따라 개별적으로 고찰할 것이라고 하며, 그리하여 가압류와 다툼의 대상(계쟁물)에 관한 가치분에 있어서는 피보전

36) 그리하여 원칙적으로 제1심 법원의 법원서기관·법원사무관·법원주사 또는 법원주사보(이를 “법원사무관등”이라고 한다)가 내어주며, 소송기록이 상급심에 있는 때에는 그 법원의 법원사무관등이 내어준다(민집 제28조 제2항).

37) 柳川眞佐夫, “被保全權利關係の承繼と保全處分手續”, 保全處分の體系(上卷): 吉川大二郎博士還曆記念, 160.

38) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(6), 367.; 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(7), 370.

39) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅳ), 23.

권리가 승계되면 일반적으로 보전의 필요성도 인정되는 것으로 볼 수 있어 통상의 소송절차에서의 승계와 같이 취급하면 될 것이지만, 임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 경우 보전의 필요성이 종전 당사자의 개인적 사정과 불가분의 관계에 있는 경우에는 피보전권리의 승계만으로 당연히 보전의 필요성에 대한 승계를 인정할 수는 없다고 보고 있다.

결국 이에 따를 경우, 가압류명령의 경우에는 피보전권리가 승계되면 보전의 필요성을 인정할 수 있게 되므로 승계집행문을 부여할 때에 다시 보전의 필요성을 심사할 필요가 없다고 말할 수 있겠다.

채무자 또는 그 승계인에 있어서 보전의 필요성을 다툼에 있어서는 집행문의 부여등에 관한 이의신청(민집 제34조) 혹은 집행문부여에 대한 이의의 소(민집 제45조) 등의 집행법상의 절차, 아니면 보전이의의 신청(민집 제283조) 또는 사정변경에 의한 보전취소의 신청(민집 제288조) 등의 보전처분상의 절차에 의해야 한다.

[7 - 1] 승계집행문 부여신청서[손해배상(기)]

승계집행문부여신청

사 건 2018가단 000호(손해배상(기))
원 고 ○ ○ ○
피 고 ○ ○ ○

위 당사자간 귀 원 2018가단000호 손해배상(기) 청구사건에 관하여 동 법원에서 2018. . . 선고한 판결은 확정되었던 바, 피고 이○○이 2018. . . 사망하여 상속인 ○○○가 그 지위를 승계하였으므로 위 승계인에 대하여 강제집행 할 수 있는 위 판결정본에 집행문을 부여하여 주시기 바랍니다.

첨 부 서 류

1. 가족관계증명서(피고) 1통

20

위 원고 ○ ○ ○ ㉠

○ ○ 지방법원 귀 중

[7 - 2] 승계집행문 및 승계사실증명서등본 송달신청서

승계집행문 및 승계사실증명서

등본송달신청

사	건	2017가단 000호(손해배상(기))
원	고	○ ○ ○
피	고	○ ○ ○
원고 승계인(채권양수인)		○ ○ ○
	주 소	

위 당사자간 귀 원 2017가단000호 손해배상(기) 청구사건에 관하여, 원고 승계인은 위 사건의 소송물을 변론종결 후인 2018. . . 승계한 채권양수인으로서, 귀 원으로부터 2018. . . 가집행선고부 판결정본 및 승계집행문과 승계를 증명하는 증명서 등본을 피고에게 송달하여 주시기를 바랍니다.

20 . . .

위 원고 승계인(채권양수인) ○ ○ ○ ㉠

○ ○ 지방법원 귀 중